GRUPO I – CLASSE VII – Plenário
TC 007.807/2022-8
Natureza: Representação
Entidades: Laboratório Químico Farmacêutico do Exército, Laboratório Farmacêutico da Marinha e Centro de Aquisições Específicas da Aeronáutica/Ministério da Defesa; Instituto de Tecnologia em Fármacos da Fundação Oswaldo Cruz/Ministério da Saúde
Responsável: Sulminas Suplementos e Nutrição Ltda (22.528.133/0001-78).
Representação legal: Beatriz Dufflis Fernandes (206.281/OAB-RJ), representando Sulminas Suplementos e Nutrição Ltda.

SUMÁRIO: REPRESENTAÇÃO APARTADA PARA APURAR SUPOSTA PARTICIPAÇÃO DE EMPRESA EM VÁRIAS LICITAÇÕES, FAZENDO USO, DE MODO INDEVIDO, DA CONDIÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE. OITIVA. ARGUMENTOS APRESENTADOS INCAPAZES DE ELIDIR A OCORRÊNCIA DA IRREGULARIDADE. FRAUDE À LICITAÇÃO. CONHECIMENTO E PROCEDÊNCIA. DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE.

RELATÓRIO

Cuidam os autos de representação autuada de forma apartada ao TC 022.765/2020-4, para apurar possíveis fraudes cometidas pela empresa Sulminas Suplementos e Nutrição Ltda. ME ao participar de diversas licitações realizadas pelo Laboratório Químico Farmacêutico do Exército, pelo Laboratório Farmacêutico da Marinha/RJ, pelo Centro de Aquisições Específicas e pelo Instituto de Tecnologia em Fármacos – MS.

2. Por meio de despacho, autorizei a realização de oitiva da referida empresa, com fundamento no art. 250, inciso V, c/c o art. 237, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, em razão das seguintes irregularidade e conduta:

"a.1) Irregularidade: Participação indevida com o usufruto do tratamento jurídico previsto na Lei Complementar 123/2006 nos pregões eletrônicos: 9/2019 e 4/2020 do Laboratório Químico Farmacêutico do Exército; 37 e 38/2018, 36/2019, 6/2020 e 5/2021, todos do Laboratório Farmacêutico da Marinha/RJ; 25/2019 do Centro de Aquisições Específicas, e 18, 59, 64, 83, 87, 111, 114, 116, 124 e 125/2019, 2, 3, 36, 83, 93 e 105/2020, 23 e 38/2021, todos do Instituto de Tecnologia em Fármacos, por apresentar as condições vedadas no art. 3º, § 4º, inciso IV da referida lei.

a.2) Conduta: a empresa Sulminas Suplementos e Nutrição Ltda ME, como licitante nos pregões acima listados, participou indevidamente de certames usufruindo o tratamento jurídico previsto na Lei Complementar 123/2006, mesmo apresentando as condições proibitivas estabelecidas no art. 3º, § 4º, inciso IV, da referida lei".

3. Cumprida a medida processual, o auditor da SecexDefesa elaborou a instrução transcrita parcialmente a seguir com os ajustes de forma que entendi pertinentes:

"9. Os argumentos da empresa ouvida podem ser assim sintetizados (peças 43-45):

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 71968518.

*a) em todas as licitações em que a empresa investigada se sagrou vencedora foram observados os ditames legais, ofertando-se os **melhores valores dentre os participantes**, beneficiando-se assim a própria Administração pelo menor preço no fornecimento dos produtos que licitou;*

*b) alguns dos itens licitados nem mesmo exigiram participação **exclusiva** de microempresa e empresa de pequeno porte, a exemplo dos pregões de nº 9/19 (itens 48 e 54, respectivamente na pasta nº 6, p. 122-124); nº 36/19 (itens 15, 16 e 19, respectivamente pasta nº 21, p. 65 e 66); nº 6/20 (item 10, na pasta 22, p. 87) e nº 5/21 (item 1, pasta 23, p. 48);*

c) a empresa investigada não violou o art. 3º, § 4º, inc. IV, da LC 123/2006, pois apesar de o "(ex)sócio" ter 90% da participação em outra empresa, detinha apenas 10% de participação na empresa Sulminas Suplementos e Nutrição Ltda ME;

d) não se verificou a profusão de sociedades, mas de apenas duas e apenas uma com regime diferenciado, bem como a participação em menor grau no corpo social (apenas 10%);

e) o sócio que detinha apenas 10% (dez por cento) das cotas da empresa investigada acabava por ter pouco poder de influência em razão de sua pequena participação no capital social, em contraposição com o restante do capital social (90%) que era detido por apenas uma pessoa, assim não haveria influência de um mesmo sócio nas decisões de ambas as sociedades, novamente afastando o que o legislador buscou evitar com a regra do art. 3º, § 4º, IV, da LC 123/2006;

f) apesar de deter na outra sociedade 90% (noventa por cento) das cotas sociais, o sócio detinha apenas 10% do capital social da Investigada, foi, portanto, observado axiologicamente o disposto no art. 3º, § 4º, inc. IV, da LC 123/2006;

g) ainda que se entenda ter havido violação do disposto no art. 3º, § 4º, inc. IV, da LC 123/2006, é inequívoca a absoluta boa-fé no comportamento da empresa investigada, que desfigura a natureza de fraude de sua conduta, porquanto não há prova alguma do dolo de fraudar, como, ao contrário, há inequívocos elementos de boa-fé da investigada;

h) todos os contratos sociais eram públicos, estavam às claras e eram de conhecimento da Administração Federal, o que evidencia que os sócios da investigada nunca esconderam a participação das sociedades que integravam;

i) a investigada nunca foi excluída do Simples Nacional, mesmo sendo de conhecimento da Fazenda o seu faturamento e corpo social (peça 45) e se a exclusão é imediata e deve ser comunicada ao contribuinte, o fato de nunca terem sido noticiados de irregularidades reforça a sua confiança na correção de sua conduta; e

j) em atenção à proporcionalidade e à razoabilidade, no remoto caso de declaração de inidoneidade do licitante fraudador para participar de licitação na Administração Pública Federal, que seja imposta à investigada a sanção no seu patamar jurisprudencial mínimo, qual seja, 3 (três) meses.

10. A empresa Sulminas Suplementos e Nutrição Ltda ME ainda apresenta documentação que atesta alteração do seu quadro social com a exclusão do Sr. Marcelo Luís Mazzaro e consequente transformação da sociedade empresária limitada em sociedade limitada unipessoal (peça 44).

Análise

11. De plano, esclareça-se que não se está aqui a verificar o atendimento do princípio da vantajosidade ou da economicidade no presente caso. Portanto, não se discute aqui se as contratações atenderam ou não de maneira mais vantajosa e econômica os interesses da administração.

12. Quanto a inexistirem licitações em que se exigia com exclusividade a participação de microempresas ou empresas de pequeno porte, beneficiárias do regime diferenciado instituído pela LC 123/2006, em nada favorece a empresa ouvida, vez que tal fato é irrelevante para apuração da

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 71968518.

conduta administrativa reprovável sob análise. Interessa apenas se em algum dos certames promovidos ela participou como microempresa não podendo ser assim considerada ante a vedação expressa do art. 3º, § 4º, inc. IV, da LC 123/2006. Sequer é relevante que tenha se beneficiado dessa condição.

*13. A jurisprudência do TCU é pacífica no sentido de que a **mera participação** em licitações reservadas a ME/EPP, por licitantes que não se enquadrem na definição legal dessas categorias, **constitui fraude à licitação** e **enseja declaração de inidoneidade do fraudador**, não necessitando que a autora da fraude obtenha a vantagem esperada, como indicam, por exemplo, os Acórdãos 3.217/2010, 1.702/2017, relator Ministro Walton Alencar Rodrigues; 3.617/2013, relator Ministro José Jorge; 48/2014, relator Ministro Benjamin Zymler; e 1.593/2019, relator Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, todos do Plenário.*

14. A empresa ouvida não se desincumbiu do ônus de provar que um de seus sócios não possuía mais de 10% do capital social de outra empresa, visto que o Sr. Marcelo Luis Mazzaro era sócio da empresa Sulminas Suplementos e Nutrição Ltda ME (peça 5, p. 3) e possui participação de 90 % no capital social de outra empresa, no caso a empresa Sul de Minas Ingredientes Ltda ME (peça 4, p. 3), isto é, superior a 10%. Assim, verifica-se que há o atendimento da primeira condição para aplicação da restrição legal da Lei Complementar 123/2006, art. 3º, § 4º inciso IV.

15. Igualmente não foi capaz de desconstituir a prova de que a receita bruta somada da empresa Sulminas Suplementos e Nutrição Ltda ME e da empresa Sul de Minas Ingredientes Ltda ME extrapola o valor previsto para o enquadramento como EPP, que foi de R$ 3.600.000,00 até 31/12/2017, e de R$ 4.800.000,00 a partir de 1/1/2018. Apenas defendeu que não haveria influência de um mesmo sócio nas decisões de ambas as sociedades.

16. Novamente tal argumento não lhe socorre, visto que não se busca aferir a influência desse sócio em ambas sociedades empresárias, e sim se a empresa participou na condição de microempresa não podendo se valer dessa condição em virtude da vedação estampada no art. 3º, § 4º, inc. IV, da LC 123/2006.

*17. Incontestável é que a empresa ouvida apresentou **declaração falsa** no sentido de que estaria apta a usufruir o tratamento diferenciado destinado a microempresas e empresas de pequeno porte por duas razões. A primeira apoia-se no fato de que seu ex-sócio, Sr. Marcelo Luis Mazzaro, possui 90% do capital da empresa Sul de Minas Ingredientes Ltda ME (peça 5, p. 3; peça 4, p. 3). E a segunda, na soma das receitas brutas de ambas empresas, que, no ano de 2017, já ultrapassava o limite de R$ 3.600.000,00, montando a quantia de R$ 3.885.384,59. Já nos anos de 2018, 2019 e 2020, a receita bruta oriunda da soma das receitas das empresas foi no valor de R$ 5.271.676,62, R$ 7.029.512,03 e R$ 12.329.974,07, respectivamente, ultrapassando o limite atualizado para enquadramento de empresas como sendo de pequeno porte, no valor de R$ 4.800.000,00 (peça 33, p. 13), afrontando, portanto, a vedação constante do art. 3º, § 4º, inc. IV, da LC 123/2006.*

18. Quanto à inocorrência de dolo ou atuação de boa-fé, tais elementos não são considerados no tipo administrativo estampado no art. 46, da Lei 8.443/92. No caso, se perquire única e exclusivamente a constatação de fraude à licitação, que resta consubstanciada na participação em certame federal na condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte de firma que não possui as condições legais para tanto. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes do TCU:

> ***Acórdão 1702/2017-TCU-Plenário*** *(relator Ministro Walton Alencar Rodrigues)*
>
> *"A mera participação de licitante como microempresa ou empresa de pequeno porte, amparada por declaração com conteúdo falso, configura fraude à licitação e enseja a aplicação das penalidades da lei, não sendo necessário, para a configuração do ilícito, que a autora da fraude obtenha a vantagem esperada."*

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 71968518.

Acórdão 61/2019-TCU-Plenário *(relator Ministro Bruno Dantas)*

"A mera participação de licitante como microempresa ou empresa de pequeno porte, ou ainda como cooperativa (art. 34 da Lei 11.488/2007) , amparada por declaração com conteúdo falso de enquadramento nas condições da LC 123/2006, configura fraude à licitação e enseja a aplicação da penalidade do art. 46 da Lei 8.443/1992, não sendo necessário, para a configuração do ilícito, que a autora da fraude obtenha a vantagem esperada."

Acórdão 2891/2019-TCU-Plenário *(relator Ministro-Substituto André de Carvalho)*

"Constitui fraude à licitação, ensejando a declaração de inidoneidade do fraudador, a mera participação em certames licitatórios de pessoa jurídica autodeclarada como microempresa ou empresa de pequeno porte, visando os benefícios concedidos pela LC 123/2006, que tenha participação societária em outra pessoa jurídica, fato que contraria o art. 3º, § 4º, inciso VII, dessa lei, bem como sua finalidade."

19. O fato de a investigada nunca ter sido excluída do Simples Nacional, mesmo sendo de conhecimento da Fazenda Pública o seu faturamento e o seu corpo social (peça 45) também não se lhe aproveita, porquanto um possível erro administrativo não convalida o outro.

20. No que tange ao requerimento da empresa ouvida para que seja declarada inidônea para participar de licitações na Administração Pública Federal por 3 meses, esclareça-se que a dosimetria da pena é tarefa privativa do colegiado deste tribunal que apreciará o processo, que examinará o caso concreto e as condições de contorno que o definem, ficando ao seu alvitre a definição do tempo da pena.

21. Por fim, a exclusão recente do Sr. Marcelo Luis Mazzaro do quadro societário da empresa Sulminas Suplementos e Nutrição Ltda ME (peça 44) não tem o condão de elidir a responsabilidade da pessoa jurídica ora ouvida, em razão de que os fatos que constituíram o objeto da oitiva promovida foram praticados na época em que fazia parte dessas empresas.

22. No caso sub examine, haja vista a vedação da própria LC 123/2006, a empresa Sulminas Suplementos e Nutrição Ltda. ME não poderia ter apresentado declaração de que se enquadrava como ME ou EPP, tendo incidido em fraude à licitação, passível da aplicação da penalidade insculpida no art. 46 da Lei 8.443/1992.

CONCLUSÃO

23. A empresa ouvida não se desincumbiu do ônus de provar que um de seus sócios não possuía mais de 10% do capital social de outra empresa, visto que o Sr. Marcelo Luis Mazzaro era sócio da empresa Sulminas Suplementos e Nutrição Ltda ME (peça 5, p. 3) e possui participação de 90 % no capital social de outra empresa, no caso a empresa Sul de Minas Ingredientes Ltda ME (peça 4, p. 3), isto é, superior a 10%.

24. Também não foi capaz de desconstituir a prova de que a receita bruta somada da empresa Sulminas Suplementos e Nutrição Ltda ME e da empresa Sul de Minas Ingredientes Ltda ME extrapola o valor previsto para o enquadramento como EPP, que foi de R$ 3.600.000,00 até 31/12/2017, e de R$ 4.800.000,00 a partir de 1/1/2018.

25. Sendo assim, a presente representação deve ser considerada procedente, para declarar a inidoneidade da empresa Sulminas Suplementos e Nutrição Ltda ME para participar de licitações na Administração Pública Federal por até 5 anos, nos termos do art. 46, da Lei 8.443/92.

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 71968518.

PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

26. Diante do exposto, submetem-se os autos à consideração superior, propondo-se:

a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes nos arts. 235 e 237, VI, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1º, da Resolução/TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la procedente;

b) declarar a inidoneidade da empresa Sulminas Suplementos e Nutrição Ltda ME, com fundamento no art. 46 da Lei 8.443/1992, para participar de licitação e contratar com a Administração Pública Federal ou de certame no qual haja utilização de recursos federais, tendo em vista a participação indevida com o usufruto do tratamento jurídico previsto na Lei Complementar 123/2006 nos pregões eletrônicos: 9/2019 e 4/2020 do Laboratório Químico Farmacêutico do Exército; 37 e 38/2018, 36/2019, 6/2020 e 5/2021, todos do Laboratório Farmacêutico da Marinha/RJ; 25/2019 do Centro de Aquisições Específicas, e 18, 59, 64, 83, 87, 111, 114, 116, 124 e 125/2019, 2, 3, 36, 83, 93 e 105/2020, 23 e 38/2021, todos do Instituto de Tecnologia em Fármacos, por apresentar as condições vedadas no art. 3º, § 4º, inciso IV, da LC 123/2006, circunstância que caracteriza fraude à licitação;

c) informar à empresa Sulminas Suplementos e Nutrição Ltda ME. e aos órgãos listados na alínea anterior que o conteúdo da deliberação que vier a ser proferida poderá ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e

d) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, III, do Regimento Interno/TCU."

4. O corpo diretivo da unidade técnica aquiesceu ao aludido encaminhamento.

É o relatório.

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 71968518.

VOTO

Cuidam os autos de representação autuada de forma apartada ao TC 022.765/2020-4, para apurar possíveis fraudes cometidas pela empresa Sulminas Suplementos e Nutrição Ltda. ME ao participar de diversas licitações realizadas pelo Laboratório Químico Farmacêutico do Exército, pelo Laboratório Farmacêutico da Marinha/RJ, pelo Centro de Aquisições Específicas e pelo Instituto de Tecnologia em Fármacos – MS.

2. Por meio de despacho, autorizei a realização de oitiva da referida empresa, com fundamento no art. 250, inciso V, c/c o art. 237, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, em razão das seguintes irregularidade e conduta:

> *"a.1) Irregularidade: Participação indevida com o usufruto do tratamento jurídico previsto na Lei Complementar 123/2006 nos pregões eletrônicos: 9/2019 e 4/2020 do Laboratório Químico Farmacêutico do Exército; 37 e 38/2018, 36/2019, 6/2020 e 5/2021, todos do Laboratório Farmacêutico da Marinha/RJ; 25/2019 do Centro de Aquisições Específicas, e 18, 59, 64, 83, 87, 111, 114, 116, 124 e 125/2019, 2, 3, 36, 83, 93 e 105/2020, 23 e 38/2021, todos do Instituto de Tecnologia em Fármacos, por apresentar as condições vedadas no art. 3º, § 4º, inciso IV da referida lei.*
>
> *a.2) Conduta: a empresa Sulminas Suplementos e Nutrição Ltda ME, como licitante nos pregões acima listados, participou indevidamente de certames usufruindo o tratamento jurídico previsto na Lei Complementar 123/2006, mesmo apresentando as condições proibitivas estabelecidas no art. 3º, § 4º, inciso IV, da referida lei".*

3. Cumprida a medida processual, a sociedade empresária apresentou os seguintes argumentos, em apertada síntese:

a) em todas as licitações nas quais a empresa se sagrou vencedora, foram observados os ditames legais, ofertando-se os melhores valores dentre os participantes, de sorte que a própria administração se beneficiou do menor preço;

b) alguns dos itens licitados nem mesmo exigiram participação exclusiva de microempresa e empresa de pequeno porte (citou);

c) não violou o art. 3º, § 4º, inc. IV, da Lei Complementar 123/2006, pois apesar de o ex-sócio deter 90% da participação em outra empresa, possuía apenas 10% de participação na empresa Sulminas Suplementos e Nutrição Ltda ME;

d) não se verificou a profusão de sociedades, mas de apenas duas, sendo que uma possuía regime diferenciado; o sócio com 10% das cotas da empresa Sulminas Suplementos e Nutrição Ltda. ME possuía pouco poder de influência nesta; assim, não haveria influência de um mesmo sócio nas decisões de ambas as sociedades, novamente afastando o que o legislador buscou evitar com a regra do art. 3º, § 4º, IV, da Lei Complementar 123/2006;

e) ainda que se entenda ter havido violação do referido dispositivo, é inequívoca a boa-fé no comportamento da empresa representada, o que desfigura a natureza de fraude de sua conduta, porquanto não há prova alguma do dolo de fraudar;

g) todos os contratos sociais eram públicos, estavam às claras e eram de conhecimento da administração federal, o que evidencia que os sócios da investigada nunca esconderam a participação das sociedades que integravam;

h) a representada nunca foi excluída do Simples Nacional, mesmo sendo de conhecimento da Fazenda o seu faturamento e corpo social; considerando que a exclusão é imediata e deve ser

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 71968522.

comunicada ao contribuinte, o fato de nunca terem sido noticiados de irregularidades reforça a sua confiança na correção de sua conduta; e

i) em atenção à proporcionalidade e da razoabilidade, *"no remoto caso de declaração de inidoneidade do licitante fraudador para participar de licitação na Administração Pública Federal, que seja imposta à investigada a sanção no seu patamar jurisprudencial mínimo, qual seja, 3 (três) meses"*.

4. A SecexDefesa analisou os elementos acostados e concluiu que eles não se mostraram aptos a elidir a irregularidade, uma vez que a empresa Sulminas Suplementos e Nutrição Ltda. ME participou de alguns certames licitatórios, usufruindo da condição de empresa de pequeno porte, apesar de incorrer na vedação expressa do art. 3º, § 4º, inc. IV, da LC 123/2006.

5. Ademais, a sociedade empresária não refutou a constatação de que a sua receita bruta somada com a da empresa Sul de Minas Ingredientes Ltda ME extrapolava o valor previsto para o enquadramento como EPP, que foi de R$ 3.600.000,00 até 31/12/2017, e de R$ 4.800.000,00 a partir de 1/1/2018.

6. Sendo assim, propôs que a presente representação fosse conhecida e, no mérito, que fosse considerada procedente, a fim de que fosse declarada a inidoneidade da empresa representada para participar de licitação e contratar com a administração pública federal ou de certame no qual haja utilização de recursos federais, nos termos do art. 46 da Lei 8.443/1992.

7. O corpo diretivo da unidade técnica aquiesceu ao aludido encaminhamento.

8. Feito esse necessário resumo, passo a decidir.

9. Ratifico o exame preliminar de admissibilidade e conheço da presente representação, haja vista o preenchimento dos requisitos aplicáveis à espécie.

10. Quanto ao mérito, manifesto-me de acordo com a análise da SecexDefesa e incorporo seus fundamentos como razão de decidir, sem prejuízo das considerações a seguir.

11. O art. 3º, § 4º, inc. IV, da Lei Complementar 123/2006 prescreve o seguinte:

> *"Art. 3º Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se microempresas ou empresas de pequeno porte, a sociedade empresária, a sociedade simples, a empresa individual de responsabilidade limitada e o empresário a que se refere o art. 966 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), devidamente registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso, desde que:*
>
> [...]
>
> *II - no caso de empresa de pequeno porte, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais). (Redação dada pela Lei Complementar nº 155, de 2016)*
>
> [...]
>
> *§ 4º Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado previsto nesta Lei Complementar, incluído o regime de que trata o art. 12 desta Lei Complementar, para nenhum efeito legal, a pessoa jurídica:*
>
> [...]

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 71968522.

IV - cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra empresa não beneficiada por esta Lei Complementar, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput deste artigo;"

12. No caso, verifico que o Sr. Marcelo Luis Mazzaro era sócio das empresas Sulminas Suplementos e Nutrição Ltda ME e Sul de Minas Ingredientes Ltda ME, possuindo, respectivamente, 10% e 90% de suas contas sociais. A soma da receita bruta das referidas empresas atingiu, nos anos de 2018, 2019 e 2020, os valores de R$ 5.271.676,62, R$ 7.029.512,03 e R$ 12.329.974,07, superando, portanto, o limite estabelecido na referida norma para enquadramento como EPP.

13. Dessa forma, resta assente que a empresa representada não poderia se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado previsto na Lei Complementar 123/2006, uma vez que incorreu na vedação estipulada em seu art. 3º, § 4º, inc. IV, durante os exercícios de 2018, 2019 e 2020.

14. Com isso, concluo que a sociedade empresária Sulminas Suplementos e Nutrição Ltda ME participou indevidamente dos pregões indicados pela SecexDefesa, porquanto apresentou declaração falsa no sentido de que estaria apta a usufruir do benefício de EPP.

15. Com relação à tipificação da conduta da empresa, a jurisprudência do TCU é pacífica no sentido de que a mera participação em licitações reservadas a ME/EPP, por licitante que não se enquadre na definição legal dessas categorias, constitui fraude à licitação e enseja declaração de inidoneidade do fraudador, mesmo que este não usufrua da vantagem esperada (Acórdãos 3.217/2010, 1.702/2017, relator Ministro Walton Alencar Rodrigues; 3.617/2013, relator Ministro José Jorge; e 1.593/2019, relator Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, todos do Plenário).

16. Logo, reputo adequado declarar a inidoneidade da empresa Sulminas Suplementos e Nutrição Ltda ME, para participar de licitação na Administração Pública Federal ou que seja custeada por recursos federais, com fulcro no art. 46 da Lei 8.443/1992.

17. Com relação à dosimetria, existem vários precedentes no âmbito deste Tribunal, a exemplo dos Acórdãos 1.797/2014, 740/2014 e 1.853/2014, todos do Plenário, nos quais houve o abrandamento da pena para empresas que não usufruíram indevidamente de benefícios com a apresentação de declaração fraudulenta. Observo, inclusive, certa convergência no **quantum** da sanção em 3 e 6 meses, consoante os Acórdãos 1.677/2018, 2.549/2019, 930/2022 e 1.488/2022, todos do Plenário.

18. No caso, verifico que a empresa praticou diversas fraudes entre 2018 e 2021, em licitações promovidas pelo Laboratório Químico Farmacêutico do Exército, pelo Laboratório Farmacêutico da Marinha/RJ, pelo Centro de Aquisições Específicas e pelo Instituto de Tecnologia em Fármacos.

19. Considerando o caráter reiterado do comportamento irregular da empresa e a dosimetria usada pelo Tribunal em casos similares, fixo o valor da sanção em 1 (um) ano.

20. Diante de todo o exposto, VOTO por que seja adotada a deliberação que ora submeto a este Colegiado.

TCU, Sala das Sessões, em 5 de outubro de 2022.

BENJAMIN ZYMLER
Relator

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 71968522.

ACÓRDÃO Nº 2162/2022 – TCU – Plenário

1. Processo nº TC 007.807/2022-8.
2. Grupo I – Classe de Assunto VII - Representação:
3. Interessados/Responsáveis:
3.1. Responsável: Sulminas Suplementos e Nutrição Ltda (22.528.133/0001-78)..
4. Entidades: Laboratório Químico Farmacêutico do Exército, Laboratório Farmacêutico da Marinha e Centro de Aquisições Específicas da Aeronáutica/Ministério da Defesa; Instituto de Tecnologia em Fármacos da Fundação Oswaldo Cruz/Ministério da Saúde.
5. Relator: Ministro Benjamin Zymler.
6. Representante do Ministério Público: não atuou.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública (SecexDefes).
8. Representação legal: Beatriz Dufflis Fernandes (206.281/OAB-RJ), representando Sulminas Suplementos e Nutrição Ltda.

9. Acórdão:

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação autuada de forma apartada ao TC 022.765/2020-4, para apurar possíveis fraudes cometidas pela empresa Sulminas Suplementos e Nutrição Ltda. ao participar de diversas licitações realizadas pelo Laboratório Químico Farmacêutico do Exército, pelo Laboratório Farmacêutico da Marinha/RJ, pelo Centro de Aquisições Específicas e pelo Instituto de Tecnologia em Fármacos – MS,

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em:

9.1. conhecer da representação, com fulcro nos arts. 235 e 237, inciso VI, do Regimento Interno do TCU, para, no mérito, considerá-la procedente;

9.2. declarar a inidoneidade da empresa Sulminas Suplementos e Nutrição Ltda., com fundamento no art. 46 da Lei 8.443/1992, para participar de licitação e contratar com a Administração Pública Federal ou de certame no qual haja utilização de recursos federais, pelo prazo de 1 (um) ano;

9.3. dar ciência desta deliberação à referida empresa; e

9.4. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, III, do Regimento Interno/TCU.

10. Ata n° 38/2022 – Plenário.
11. Data da Sessão: 5/10/2022 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-2162-38/22-P.

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 71968534.

13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Bruno Dantas (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues, Benjamin Zymler (Relator), Aroldo Cedraz, Jorge Oliveira e Antonio Anastasia.
13.2. Ministros-Substitutos convocados: Augusto Sherman Cavalcanti, Marcos Bemquerer Costa e Weder de Oliveira.

(Assinado Eletronicamente)
BRUNO DANTAS
Vice-Presidente, no exercício da Presidência

(Assinado Eletronicamente)
BENJAMIN ZYMLER
Relator

Fui presente:

(Assinado Eletronicamente)
CRISTINA MACHADO DA COSTA E SILVA
Procuradora-Geral

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 71968534.